

1500464-38.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500464-38.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500464-38.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058931/2022 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 23346516 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 12/22/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2058931 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE JESUS DOS SANTOS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

KAIQUE JESUS DOS SANTOS qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de março de 2022, pela manhã, na Avenida Cláudio Ferreira Cesário, nº 800, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em 62 (sessenta e duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 8,67 gramas, e 69 (sessenta e nove) porções de cocaína em forma de crack, com peso líquido aproximado de 10,56

gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 20/31 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 83/85, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, KAIQUE trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Guardas Municipais realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram KAIQUE. Ao notar a presença da guarnição, o denunciado dispensou algo ao chão e empreendeu fuga.

Os guardas perseguiram KAIQUE, até que conseguiram abordá-lo.

Realizada busca pessoal no denunciado, foi apreendida a importância de R\$ 50,00. Indagado, KAIQUE admitiu que aquele valor era oriundo da venda das porções de entorpecentes.

Os guardas municipais retornaram ao local onde KAIQUE havia dispensado um objeto e localizaram uma sacola plástica, dentro da qual havia seis papелotes de cocaína, sessenta e nove papелotes de cocaína em forma de crack e quatro pinos de cocaína.

KAIQUE confessou que toda a droga era destinada ao comércio. O denunciado também indicou o local onde guardava as porções destinadas à venda. Assim, em um terreno baldio, os guardas apreenderam mais cinquenta e dois pinos de cocaína, drogas estas idênticas às anteriormente apreendidas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14).

Sobreveio a prisão em flagrante de KAIQUE

Distribuído o auto de prisão em flagrante, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/59).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado em 23/03/2022 (fls. 93/96).

O acusado foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa prévia (fls. 113/114).

A denúncia foi recebida em 29/05/2022 (fls.121).

O réu foi devidamente citado (fls. 132).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e o réu foi interrogado (fls.143).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.143).

Em alegações finais escritas, a defesa, pugnou, em sede de preliminar, pela nulidade do feito tendo em vista que, ao seu ver, as provas foram obtidas por meios ilícitos e em consequência disso, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, VI e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, teceu comentários em relação a aplicação da pena (fls.145/157).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Primeiramente, cumpre trazer à baila a questão levanta pela defesa em sede de preliminar.

A guarda municipal, embora não esteja investida de atividade de polícia ostensiva e possua como atribuição funcional primordial o resguardo de bens, serviços e instalações do município, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibindo a prática de delitos, mormente quando este ocorre em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção. Aliás, inexistente obstáculo para que integrantes da guarda municipal efetuem a prisão em flagrante, eis que esta pode ser realizada por qualquer um do povo.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação. 2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Ainda, o E. STF no Recurso Extraordinário - RE 1281774 com relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a legalidade da prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais, conforme segue:

[...] As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.

[...] As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve.

CONCLUSÃO: Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para RECONHECER A LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE realizada pelos guardas municipais e CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida nos autos do processo criminal nº 1500389-30.2018.8.26.0599.

Do mesmo modo, não prospera a alegação da ilegalidade da prova, uma vez que, conforme demonstrado acima, a mesma foi obtida por meios legais.

Assim, fica afastada a preliminar suscitada pela defesa.

Na questão de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls.01); o boletim de ocorrência (fls. 12/13); o auto de exibição e apreensão (fls.14); o laudo de constatação (fls. 20/31); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 83/85); o relatório (fls. 87/89); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu negou os fatos. Relatou que em nenhum momento correu dos Guardas. Afirmou que estava em frente a sua casa e os guarda já chegaram o agredindo e falando que o depoente estava no "corre", o que não procede. Relatou que faz três meses que saiu da cadeia e nunca mais se envolveu com drogas. Por fim, informou que não conheceu os guardas que o prenderam (essência do depoimento fls.143).

A testemunha GENILTON ESTANISLAU ACASSIO MACHADO, GCM, informou que estavam em patrulhamento próximo a creche do Monte Mor quando avistaram Kaique, que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou algo ao solo. Afirmou que saíram ao seu encalço, sendo que Kaique tentou pular uma cerca, próxima a horta, tropeçou e caiu possibilitando sua abordagem. Informou que em revista pessoal foi encontrado cinquenta reais. Relatou que foram até o local onde o acusado havia dispensado algo ao solo e localizaram uma sacolinha com pedras de "crack" e pinos cocaína. Ao ser indagado, o acusado informou que havia mais drogas escondidas, informando o local onde foram localizadas mais porções de cocaína (essência do depoimento fls. 143).

A testemunha THIAGO FRANCISCO LOURENÇO, GCM, informou que estavam em patrulhamento próximo ao Monte Mor quando o acusado ao avistar a viatura empreendeu fuga e dispensou algo ao solo. Afirmou que durante a fuga o mesmo tropeçou e caiu ao tentar atravessar um cerca. Quando indagado do porque havia fugido ele informou que tinha voltando a vender drogas. Em busca pessoal foi encontrado cinquenta reais com o réu. Questionaram o que o acusado havia dispensado e ele informou que se tratava de droga. Ao voltarem no local onde ele havia dispensado algo encontraram uma sacolinha com drogas. O acusado afirmou que tinha mais drogas próximo dali, mostrando aonde estava o entorpecente, em um terreno baldio (essência do depoimento fls.143).

Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os GCMs relataram, em uníssono, que estavam em patrulhamento preventivo, momento em que o acusado, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e dispensou algo no solo. Relataram que saíram em seu encalço e lograram localizar em sua posse certa quantia em dinheiro. Ainda, retornaram ao local constatando que o objeto dispensado pelo acusado tratava-se de uma sacola contendo entorpecentes. Por fim, afirmaram que, ao ser indagado, o réu confessou a traficância, inclusive, indicando o local onde foram localizados mais entorpecentes escondidos.

Os depoimentos dos GCMs foram firmes e harmônicos e se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

Por outro lado, o acusado não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e a quantidade de dinheiro encontradas, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

Além disso, o laudo de fls. 83/85 resultou positivo para cocaína em forma de "crack" e cocaína.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LIVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos GCMS são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos guardas devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo e manter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, pesando aproximadamente 8,67 gramas, e 69 porções de cocaína em forma de "crack", com peso líquido aproximado de 10,56 gramas), outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor menor.

Majoro a pena de 1/6, em razão da reincidência específica do acusado (fls. 104/106 processo nº 1500854-47.2018.8.26.0079), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão da quantidade, diversidade e potencialidade do entorpecente apreendido, bem como da reincidência específica, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR KAIQUE JESUS DOS SANTOS, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls. 14), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculado à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que

permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu 3/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 09 de setembro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA